

数字化治理背景下行政参与权遮蔽的 生成逻辑与制度因应

● 娄金炜 *

【内容摘要】 权利遮蔽是指法定权利由于客观情势变更造成的权利内容无法被完全实现的现象,环境变动和介质基础变化是其关键成因。在数字化治理中,具体行政行为中的相对人面临着行政参与权遮蔽的困境,需要系统探讨其生成逻辑。就技术引发的环境变动而言,数字化治理引发了公开行政异化、协商行政萎缩及责任行政混沌,造成了行政参与权遮蔽的不良结果;就数字化治理引发的程序介质变化而言,程序折叠下的流程结构再造和法律关系隐匿均带来了相应的行政参与权遮蔽问题。对此,宜分别从保障义务补位和权利迭代发展出发寻求解题思路,包括以实质可理解为落脚点、以有效交互为内核、以切实可问责为方向强化治理部门的行政参与权保障义务。同时,从推进技术与知情权融合、完善陈述申辩权的保障性制度群、设置人工服务可及权三方面推动行政参与权的迭代发展。

【关键词】 数字化治理 行政参与权遮蔽 技术环境变动 程序介质变化 保障义务补位 权利迭代发展

数字化治理的深入推进,正加速以技术逻辑重塑公共行政的实践图景。从“最多只跑一次”到“一网通办”再到“秒批秒办”,效率革命在大幅提升行政治理效能的同时,也改变了行政相对人权利的实现逻辑。随着算法嵌入决策、数据并联流程、系统整合职权成为治理常态,赋能效应与权利的隐性消解成为技术投射于权利领域的“二律背反”。数字化治理的推广不仅为权利提供了新的保障手段和实现路径,亦触发了权利运转环境的变迁及介质革命,由此产生了新的权利实现问题,譬如算法的瞬时决策压缩了抗辩空间、并联程序和技术黑箱折叠了参与路径等。以上权利面临遮蔽的现象,既折射出数字化治理中技术理性与权利价值的深层张力,也使行政法治围绕两者的弥合与调协形成了新的发展思路。本文以行政行为中相对人程序性的行政参与权(此“行政参与权”与社会公众参与公共行政时所行使的政治性参与权相区别,出于表达简洁考虑,下文简称“参与权”)为分析线索,重点揭示参

* 作者单位:浙江立法研究院、浙江大学立法研究院。

与权在数字化治理模式下被“遮蔽”现象的生成逻辑,进而讨论“权利找回”的制度路径。相关问题的探讨将不仅涉及个体权利在现代治理模式下的实现质量,亦关乎行政权力在数字化时代的合法性根基。

一、何为“权利遮蔽”:概念与范式

本文所谓“权利遮蔽”,指法律对权利内容的界定因客观情势变更无法被完整实现,由此产生的权利空心化问题/现象,其本质是法定权利向实在权利的转化路径发生“断裂”,导致法定权利无法兑现为能够“无损耗”实现的权能。事实上,当前与“权利遮蔽”相关的研究存量不在少数,相关的质性研究往往存在于权利演进、权利保障、权利实现(困境)、权利救济等多元化的权利性课题中。然而,这些研究尚不能替代对“权利遮蔽”的问题聚焦与系统考察,权利遮蔽研究的特殊性表现在:首先,就研究对象而言,权利遮蔽研究对象限定为法定权利,而非应有权利、实在权利或其他未经法律认证的权利。其次,就研究目标而言,“权利遮蔽”概念中所内置的问题结构决定了其研究旨趣在于权利“找回”。最后,就研究进路而言,权利遮蔽研究以权利实现状况为核心关切,以法定权利内容与当前社会经济、治理、发展等结构性错位引发的权利空心化问题为切入(不同于简单的“权利受损”),探讨恢复权利圆满状态或推进权利共时性发展的具体路径。总之,权利遮蔽研究是法学权利研究的重要分支,同时又具有相当的特殊性和不可替代性。在默认法定权利于创设之初能够较好回应利益诉求的前提下,权利遮蔽的成因大体可归结为三个方面,以下作详细讨论。

(一)权利实现的环境基础发生变动

以引发变动的驱动力为标准,可以将环境变动分为两类:

1. 制度环境的变动。即权利依赖的政治、经济、社会文化等综合条件发生变化,导致权利实现程度衰减。制度环境作为权利生成的底层框架,本质上是政治体制、经济制度、民主建设水平与社会文化素养等要素的系统集成,如民主是权利有效实现的政治基础,如果国家民主控制、制约机制缺位,即便立法中载明了权利也难以完全实现;社会文化则关乎“一国的文化背景、公民现实的心理以及普遍的智力条件”,^[1]即缺乏科学、政治、文化、技术素养的社会群体或个人在行使权利时往往会面临一定的智识阻碍。例如,2019年江苏省南京市建邺区工作的部分环卫工人接到了公司配发的一款智能手环,要求工作中必须佩戴。该智能手环的主要功能是通过数字实时定位功能确定环卫工人的行动轨迹,从而确定其是否按时出勤、有无脱离工作区域,并在环卫工人超过20分钟未移动时对其作出语音提醒。而对于这种侵犯隐私权、损害人格尊严的做法,尽管环卫工人明确表示不满,然而由于缺乏对权利内容及法律渠道的认知,大多并未明确主张自身的隐私权与人格尊严权益。此事件在被大量报道后,环卫公司仅取消了20分钟超时提醒音。^[2]应明确的是,此处的“制度环境变动”并非指单一要素的发展或倒退,而是政治文明演进、经济基础变革与社会意识转型相互作用形成的综合性变迁,当原有法定权利体系无法适配新的制度环境时,权利遮蔽便随之产生。

2. 由技术引发的环境变动(以下简称“技术环境”)。技术创新与制度创新是现代政府治理能力

[1] 舒国滢:《权利的法哲学思考》,载《政法论坛》1995年第3期,第6页。

[2] 参见《环卫工智能手环“监工”功能引争议 环卫公司:已取消》,载新华网, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629928549613650139&wfr=spider&for=pc>, 12月16日访问。

提升的“双轮驱动”,但技术发展亦造就了权利实现环境的“差序格局”,包括两层含义:其一,技术发展对于不同权利实现的意义差异巨大。有些权利借助技术得到更充分的实现,如通过数字化信息平台和政府网站建设,群众知情权得到了多渠道、大范围的稳固信息源保证;借助大数据技术,治理决策对于社情民意的敏感度大幅提升,从而在更高层次上保障了群众的综合利益。但与此同时,有些权利实现却因与技术发展的“效率”指向相悖面临被遮蔽的问题。其二,法治是技术发展背景下治愈权利遮蔽和“差序格局”的“良药”,但技术的法治化不是一蹴而就的。技术突破的初期通常会形成“超额收益—权利压缩”的非均衡利益格局,即技术拥有者获得与之付出不对等的超额收益乃至违法收益,同时他人的法定权利受到不当压缩或被侵夺。例如,在“杭州市萧山区人民检察院诉虞某某个人信息保护民事公益诉讼”一案中,虞某某利用人工智能换脸软件,将从互联网等渠道收集到的他人人脸信息与部分淫秽视频中的人脸信息进行替换合成,造成了众多社会主体个人信息权益受损。^[3]类似案件如犯罪人借助 AI 技术破解人脸识别验证,注册他人电子医保账号,盗刷他人医保账户资金近 70 万元。^[4]法治化对权利分配的调节功能使其成为前述非均衡格局的重要修复机制,通过立法、执法、司法等形式推动各项利益比值重新回到公正的范畴内。然而,技术的法治化必须要符合事态发展的规律,在技术规制的必要性、可行性未经充分验证的情况下,法治化不仅于事无补,反而可能造成更严重的失序问题。在真正实现法治化之前,法定权利被遮蔽的情况可能会一直延续下去。

(二) 权利实现的介质基础发生变化

权利实现除必要的环境基础外,还需要相应介质作为自身的凭证或载体,介质状态是判断权利实现与否的核心标准。相较于前述环境基础,介质与权利实现之间具有更为直接、稳固的关联。根据介质的形制差异,可将权利的介质分为物质类介质与程序类介质。

1. 物质类介质的变化。权利的物质类介质即以实体物作为权利凭证和权利实现的基础,典型如提单灭失、房产证或机动车登记证书的获取等,该实体物状态的变动同时意味着权利的实现、受损或消灭。当该物质类介质折损、不合理灭失或丧失法律上的象征效力时,其所承载的权利便会面临着被遮蔽的问题。例如,在数字化时代,传统纸质的借据、票据、收据具有的证明款项流动的数额、时间、流向等部分功能已经被转账记录(微信、支付宝或网络银行)所吸纳或取代,转账记录丢失灭失引发的权利遮蔽效果与借据、票据、收据的灭失几乎等同。在司法实践中,若无其他材料佐证,转账记录的丢失便意味着附着于记录之上的权利诉求无法成立。在“赵某某诉靳某某民间借贷纠纷案”中,法院认为“双方原始微信聊天记录及微信转账记录丢失,无法提供……无法证明双方就该笔款项达成了借贷合意,出借资金到达借款人的事实,故本院不予支持”。^[5]

2. 程序类介质的变化。在法治国家,程序具有独立于实体的价值,某些权利的实现以相应程序履行为基础或依据,如《行政处罚法》第 64 条,当事人及有关人员有权在举行听证七日前获取时间、地点的通知,只要行政机关在听证七日前完成了通知程序,当事人及有关人员获取听证通知的权利即告实现。当权利寄托于程序类介质时,权利实现与程序设置间存在显见的相关性,程序中是否允许当事人委托代理人,程序中的主体结构、时间期限、流程长短等,这些都直接决定了当事人权利实现的路径和水平。因此,当程序规则发生重大变化时,与原程序安排匹配的权利便面临着被遮蔽的问题。

[3] 参见浙江省杭州互联网法院(2023)浙 0192 民初 4563 号民事判决书。

[4] 参见重庆市渝中区人民法院(2024)渝 0103 刑初 395 号刑事判决书。

[5] 青海省西宁市湟中区人民法院(2025)青 0122 民初 1535 号民事判决书。

(三)行政主体主观因素造成的权利遮蔽

无论是技术环境的变动,抑或是介质基础变化,均可归于权利遮蔽的客观成因,事实上,行政主体的主观因素亦是权利遮蔽的重要成因。在此类权利遮蔽中,行政主体通常负有一定的主观过错,其可能基于执法成本、行政效率、政绩绩效等考量倾向于采用简省的行政程序或低成本的决策方案,并因此造成权利的不当减损;此外,因行政主体自身技术能力不足(难以履行新时期权利的保障义务)的非过错性主观因素引发的权利遮蔽也可归于此类。例如:在澳大利亚“机器债务案”中,澳大利亚政府为了避免社会福利的超额发放,会将税务局和福利署中关于个人收入的收据进行交叉比对,当税务局申报的个人收入数据大于福利署数据时,意味着福利署向该个人发放了超额福利,由此产生一笔需要向政府偿还的债务。然而,福利署对相对人全年收入的计算方式,是根据相对人的双周收入来推导其全年收入,因此倘若相对人的收入在一年内存在波动,福利署数据就必然不是准确的。尽管福利署会通过邮件告知相对人产生了对政府的债务,但上述债务的产生与计算方法却未必在邮件中告知。^[6]又如,2005年在北京西城区发生的“杜宝良案”中,京城市工人员杜宝良在北京同一地点违章105次、被罚款10500元,^[7]然而,相关部门却未将处罚告知当事人。以上两案中,行政主体并非不能向相对人告知,而是出于绩效、怠惰、技术能力等主观因素未告知或未充分告知,相对人权利由此受到遮蔽。然而,行政主体的主观因素作为权利遮蔽的成因,一则非数字化治理中所特有,数字化仅改变了其外观形式而未变其实质;二则主观性本身难于体察与佐证,因此本文对此种遮蔽情形不再进一步探讨。

以上主要从两个维度、四个方面(“行政主体主观因素”未计入)对权利遮蔽现象的成因展开了探讨。现实中,每一次权利遮蔽的发生往往是环境变动和介质变化彼此嵌套、连锁和叠加的结果,完全单因性的权利遮蔽在当前动态关联的社会中,很难找到实例。

二、数字化治理背景下“行政参与权遮蔽”的现实图景

随着数字化时代的到来,数字化治理的推广使相对人的程序权利遭受侵害、衰变乃至被变相剥夺的情况持续凸显。数字化治理系统可能在当事人未获通知的情况下认定其“死亡”,同时终止其的高龄补贴发放,^[8]或将无辜者判定为“潜在恐怖分子”,将其列入“禁飞”名单中。^[9]对此,激进观点认为,数字化治理(自动化)拒绝采用“个性化”程序安排,在没有充分告知或提供听证机会的情况下就对个人采取具有惩戒或负担意义的决策,制造了不稳定性 and 不确定性,颠覆了公民的生活。^[10]尽管这一阐述夸大了数字化治理的负面效果,但无可否认的是,数字化治理的技术逻辑与法治原则中的程序价值间的碰撞,动摇了现代行政法“以程序制约权力”的理念基础与功能支撑,数治时代的正当程序危机正由技术操作层面升格为宪制层面的治理正当性挑战。

相对人在行政活动中实现自身的参与权,亦是正当程序在制度与原则层面得以践行的重要表现。在我国,作为相对人在行政程序中的“行政参与权”能否归于“法定权利”范畴尚乏定论,从规范层面

[6] See Monika Zalnieriute, Lyria Bennett Moses & George Williams, The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making, *Modern Law Review*, Vol. 82:3, 2019, p. 436.

[7] 参见刘敢生、胡夏冰:《“杜宝良事件”与行政执法的程序正义》,载《长江日报》2005年6月9日,第12版。

[8] 参见梁振文:《8旬阿婆领不到高龄补贴,一查“死亡”4个月》,载《南国都市报》2019年5月9日,第7版。

[9] See Danielle Keats Citron, Technological Due Process, *Washington University Law Review*, Vol. 85:6, 2008, p. 1256.

[10] See Ryan Calo & Danielle Keats Citron, The Automated Administrative State: A Crisis of Legitimacy, Vol. 70:4, 2021, p. 819.

看:一方面,行政参与权之下的几项子权利即知情权、陈述申辩权与听证权已获得法律认证。如《行政处罚法》中明确规定当事人有要求听证的权利,并专节规定行政处罚中的听证程序;《学位法》第39条规定学位授予单位在不授予或撤销学位前,必须告知事实依据并听取申辩;《行政许可法》《反间谍法》《公职人员政务处分法》中也均可见相关规定。另一方面,作为概括性程序权利的参与权尚未被国家立法直接确认,^[11]目前仅地方立法中有关于参与权的确切规定。那么,参与权能否视作一种法定权利?对此问题的回应需结合具体研究视角:若以权利谱系拓展为目标,参与权的内涵远超“知情+陈述申辩+听证”的现行范畴,其作为开放性权利束难以被既有立法完全吸纳;但若以实在法解释为路径,将参与权视为法定子权利的集合概念,则其法定权利属性可根据现有条款证成。本文即采取后一研究视角,将参与权视作“由多项法定子权利构成的程序权利体系”,并在规范框架内展开分析。

随着正当程序面临严峻挑战,作为正当程序原则的核心要素,参与权在数字化治理的纵深推进中正遭遇系统性遮蔽,以下作进一步阐述。

(一)知情权的遮蔽

知情权是相对人(及利害关系人)“知”的权利,即知悉或获取信息的自由与权利。迄今,我国已经围绕电子商务交易中的消费者、慈善活动中的募捐对象、个人信息处理语境中的个人、各级人民代表大会代表及军人等几类主体的知情权构建了立法保障。在数字化治理的语境下,相对人获取与自身利益相关的信息是其参与权得以实现的前提和基础,且相关信息的可及性及所获信息的数量、质量,直接关系着特定治理语境中相对人参与权实现的水平。有学者将数字政府的不透明形式主要分为三种,对我们理解数字化治理中知情权遮蔽的相应情形具有启示意义。具体而言为以下几方面。

1. 基于国家秘密、商业秘密而产生的知情权遮蔽。当某项政府信息属于国家秘密或者商业秘密时,则相对人的知情权不得穿透公开豁免的帷幕得以实现。例如,在“江某诉国家金融监管总局、第三人中国银行政府信息公开、行政复议”一案中,江某向金融监管总局申请公开“中国银行向贵局备案的以‘中国银行系统、中国银行总行系统、……中国银行手机APP系统’等名称命名的系统的投产、整改等的详细内容”,对此,金融监管总局在答复函中以申请信息涉及第三方商业秘密为由拒绝公开,该答复在后续的行政复议及两审判决中均得到了支持。^[12]

2. 基于技术素养缺失的知情权遮蔽。对于受到数字化治理系统影响的大多数人来说,由于缺乏计算机、代码方面的专业知识,即使向其提供了相关系统信息,他们依然难从中提取有效内容。

3. 基于“机器学习”情境的知情权遮蔽。即在适用机器学习的数字化治理情境中,复杂的代码运行和高度综合化的数据处理使专家也难以解释决策作出的原理,^[13]更遑论未经过系统训练的普通人群了。在此类权利遮蔽情形中,相对人知情权受到的侵害很大程度源自人类思维在理解复杂事物方面的客观局限。^[14]

[11] 在北大法宝上根据“全文+参与权”检索到现行有效法律五部,分别是《未成年人保护法》《军人地位和权益保障法》《海警法》《人民检察院组织法》《人民法院组织法》。然而,这些法律条款中所规定的“参与权”均是作为民主权利侧面的宏观、政治性参与权,而非本文关注的具体行政行为中的程序性参与权。

[12] 参见北京市高级人民法院(2025)京行终6163号行政判决书。

[13] See J. Burrell, How the machine “thinks”: Understanding opacity in machine learning algorithms, Big Data & Society, 2016, p. 1-2.

[14] See Monika Zalnieriute, Lyria Bennett Moses & George Williams, The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making, Modern Law Review, Vol. 82:3, 2019, p. 442.

（二）陈述申辩权的遮蔽

陈述申辩权(可分称陈述权、申辩权)是在具体行政行为中相对人表达观点、发表异见并被合理吸纳的权利;作为参与权的核心构造,其确立本身即标志着行政风格自传统“高权命令”向“民主协商”“程序法治”的现代化转向。在数字化治理的语境下,陈述申辩权除延续了其监督与平衡的制度性功能外,更在防止算法专断、保障决策参与性、维护数字环境中“人”的主体地位与尊严等方面发挥着不可替代的规范价值。然而,该权利在数字化治理背景下正面临着被遮蔽的客观困局。决策生成的高效性是数字化治理的核心优势,在算法的加持下决策时间可以毫秒计,如广州、深圳等地在人才落户工作中引入“无人干预自动审批”,符合条件的申请人只要通过数据比对便能获得秒级审批。前述以“秒批秒办”为代表的效率革命之所以能够发生,相当程度上可归结于“简省”了以表达和沟通为核心的协商论证程序——由于相对人的陈述权与申辩权具有显著的“程序减速”效果,成为数字化治理时代决策生成中较易落空的权利。

例如,近十年来我国多地在市区主要街道口设置“行人闯红灯抓拍”警示屏,当出现行人闯红灯的情况后,包括容貌、姓名乃至身份证号(部分数字会作隐匿处理)在内的行人信息即刻便出现在大屏幕上,甚至会在屏幕上循环播放一小时之久。^{〔15〕}尽管将相对人信息公示于警示屏的行为已经构成《行政处罚法》中“警告、通报批评”行政处罚,但在此处罚决定形成之前,相对人没有任何陈述事实、表达异议的渠道。数字化治理背景下决策程序的自主性与瞬时性特征,一定程度上钳制了个人表达自由乃至表达可能性。此外,对相对人而言,陈述和申辩本身是手段而非目的,其从法定权利转化为实在权利的标志是陈述、申辩中的合理诉求在治理中被吸纳,因此如果相对人通过陈述与申辩传达了合理诉求却未被采纳,也要纳入权利遮蔽的情形。

（三）听证权的遮蔽

根据自然正义原则的要求,当作出不利于当事人的决定时应当听取本人的观点,正当程序理论兴起为听证权提供了更为坚实的法理支撑。在数字化治理的语境中,听证权除继续发挥其提升决策理性、保障民主参与的价值外,更突显出一层程序性抵抗意涵——面对封闭运行状态的治理系统,相对人得通过主张听证权明确表达其对缺乏合理性、合法性根据的决策的抵抗态度;也由此,听证权构成了相对人对抗那些封闭自足、排斥实质对话的数字化治理的关键性程序装置。然而,听证权的实现往往伴随着相应的成本要求,^{〔16〕}所以并非在所有行政行为中都可行使听证权。尽管“我国没有建立过真正意义上的‘成本—收益’分析制度,但通常情况下行政任务的设定仍要考虑或衡量人手、资源等多方面的条件约束”。^{〔17〕}我国《行政处罚法》第63条即通过“等”字条款与数额标准,将听证限定于较重大的行政处罚案件,展现出对听证成本的审慎考量。

在数字化治理中,机器学习场景下的算法始终处于自我更新与自我建构的进程之中,这导致对算法进行破译和解释时,既需回溯初始训练数据集与模型架构,又须解析实时演进的代码规则,如此产生了巨大的解码成本。而且即便如此,也未必能够获得对算法的精确解释,在“Loomis案”中,美国一家新闻网站为验证Compas系统是否存在种族歧视倾向,便向社会公开了Compas系统的运行数据,

〔15〕 参见《放大招!闯红灯,你的脸部“大头照”将刷屏……》,载环球网, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1626508767117192969&wfr=spider&for=pc>, 2025年12月3日访问。

〔16〕 为与前述的陈述申辩权论证相区隔,此处“听证权”的内涵取狭义,即相对人要求组织“听证会”以表达阐述自己观点的程序权利。

〔17〕 马怀德:《数字法治政府的内涵特征、基本原则及建设路径》,载《华东政法大学学报》2024年第3期,第14页。

并邀请刑事司法专家、统计学家、政治学家、机器学习专家等具有相关学术背景人员对数据进行解读,最终得到的解读结果却莫衷一是。^[18]以上问题体现于组织听证的价值衡量中,一方面听证的程序成本将大幅提升,另一方面治理部门难以对相对人的质疑作出准确、无可置疑的回应,这从根本上动摇了听证程序的核心功能——通过事实陈述与质证实现决策理性。最终,可能导致听证权在数字化治理实践中的功能性遮蔽。

三、数字化治理下行政参与权遮蔽的生成逻辑之一:技术环境变动

毋庸置疑,数字技术与政府治理深度融合,首先带来的是权利的积极效应。借助机器学习、大数据、云计算、人工智能等技术,数字化治理通过辅助行政决策、感知社情民意、促进政务透明、优化资源调配等方式,在提升行政效能与决策科学性的同时,显著拓宽了民众参与的渠道、增强了决策的透明度,这些积极面向利好包括参与权在内的全类型权利实现。然而,数字化治理运行囿于数据、代码搭建的量化轨道,无法识别人的尊严与主体性;难以在浩渺的利益海洋中构建起公允的价值顺位,亦无法加载对于特殊群体的仁慈与关怀——凡无法被结构化数据所捕捉的法治思想、价值、精神,均在治理数字化的进程中默然消解,并由此在局部范围内形成了高度机械的规则之治、“去人类中心化”的治理风格和“主体客体化”乃至“反权利”的环境氛围。这已经撼动了法治作为人造物的核心理念和运转范式。参与权是个体在涉及自身利益的特定行政行为中知情、协商和产生实质影响的权利,是以人的尊严和主体性地位为内核的,随着数字化治理对人的尊严、主体性发起挑战,参与权的实现环境也面临一定恶化,对此可从公开行政、协商行政、责任行政这三个参与权的“母体环境”进一步阐述。

(一)治理透明度引发公开行政异化

公开行政是现代法治的重要原则,也是参与权诞生的基本前提,其规范构造表现为权利与义务的对向展开:从权利之维来看,知情权是公开行政在权利领域的投射,既包含被动接收行政告知的消极权能,也涵盖主动申请信息公开或在听证等参与性程序中主动问询的积极权能。从义务之维来看,治理部门需履行及时、全面、真实、准确、有效的信息披露义务,消除对话中信息不对等的状况。知情权主体与披露义务主体的交互是以信息要素流通为核心的治理对话,权利、义务和信息要素是公开行政赖以运转的形式基础和动力源泉。然而,数字化治理之下的算法透明度问题在一定程度上阻塞了上述交互活动。

1. 算法特性引发的公开行政异化。算法决策的复杂性和低透明度降低了决策过程的可解释性,降低了交互中信息要素的实质价值,导致公开行政运行梗阻。事实上,并非所有算法都可以称为“黑箱”,只有那些完全不公开、不透明的算法才称得上是“黑箱”;^[19]也并非只有“算法黑箱”才会引发社会问题,低透明度和高复杂性的算法同样会触发不同程度的公开困境。(1)复杂算法运转引发解释困境。正如学者指出的,解释AI是异常困难的,AI系统被设计之初就不是为了揭示其决策过程的。^[20]一方面,机器学习模式下对信息的整合优化过程与人类所习惯的推理模式和表达模式存在结构性差

[18] See Anne L. Washington, How to Argue with an Algorithm: Lessons from the COMPAS-ProPublica Debate, Colorado Technology Law Journal, Vol. 17, No. 1, 2018, p. 149-150.

[19] 参见刘东亮:《技术性正当程序:人工智能时代程序法和算法的双重变奏》,载《比较法研究》2020年第5期,第70页。

[20] See Charlotte A. Tschider, Beyond the “Black Box”, Denver Law Review, Vol. 98: 3, 2021, p. 690.

异,由此产生了认知壁垒。^[21]例如,自动化系统对面部的识别过程可能涉及近远端关系、角度、着色、形状等多重要素的复杂组合,^[22]系统需将接收到的面部图片信息化后与数据库中存储的面部信息组合进行多次匹配,最终作出通过识别或相反的判定。但如果试图通过人类语言将每次匹配的技术过程以可理解的方式表达出来,则几乎是不可能的;思维与语言的同一性使语言上的“不可阐述性”直接造成了算法不透明乃至“黑箱”的特质。另一方面,算法始终处于自我革新的进程中,前一个决策做出后的一分钟或一小时内,算法的运转逻辑便已经发生了代差;当算法已经自动更新了多次时,再要获取某个时间点决策生成的算法解释就会变得格外困难,^[23]即便是算法的运营者也可能无从解释。(2) 专有属性算法引发公开困境。在算法由私营公司开发,经政府采购后应用于治理的情况中,出于垄断技术领域之目的,公开算法模型都被开发设计算法的私营公司以“保护商业秘密”为由反对,造成公开困境。

2. 信息过量引发的公开行政异化。在数字化治理实践中,公开行政还可能面临一重隐蔽的困境——治理部门虽然公开了海量信息,但这些信息未经整理、筛选以致于无法阅读、理解、吸收或归纳;关系到相对人权益的关键信息被隐没于技术文档和运行日志等过度曝光的数据洪流之中,使相对人不得不在堆积如山的数据中奋力搜寻有效内容,有时从这些信息中获取有效内容本身就需要算法来完成。可见,过度的信息公开本身就构成了对实质公开的威胁,其在变相限缩相对人知情权的同时不当削减了治理部门的信息披露义务,由此造成公开行政运行梗阻。有学者指出,算法治理中更宜采用“理性透明度”而非“鱼缸透明度”,即更注重披露决策解释逻辑和有价值性的信息,而不是公开所有决策中的技术细节。^[24]

(二) 技术治理逻辑引发协商行政“萎缩”

“协商”是现代行政参与权的核心机制,可以从形式和实质两个层面出发理解“协商行政”:形式层面上,协商行政要求构建平等的对话空间和沟通程序,使基于知情权行使获取的信息转化为协商中的观点和论据;实质层面上,协商行政要求构建制度性反馈,将相对人在协商过程中表达出的合理意愿以合理的形式、比例、内容体现于决策之中。哈贝马斯曾指出:“民主的意见形成和意志形成过程的程序和交往预设的作用,是为一个受法律和法规约束的行政部门的决策提供商谈合理化的重要渠道”。^[25]换言之,合理合法合规的部门决策一方面要遵循民主意志的形成过程,即民主程序;另一方面要强调经过民主程序所形成的是“民主的意见”,即决策动议中包含相对人意愿的因子。目前,数字化治理所适用的技术治理逻辑在一定程度上导致了协商行政的程序性退却和实质空心化的问题。

1. 技治逻辑压缩了协商行政的程序适用空间。具体又可以分为两类情况:(1) 瞬时决策排除了协商空间和反馈路径。前面提到的“行人闯红灯抓拍”案例中,由于行政处罚的作出只在毫厘之间,事实性地排除了相对人与治理部门协商对话的可能性。又如,在“陈明春、方育鸿诉萧山区住建局案”中,由于自动化房屋合同备案系统存在缺陷,原告原本符合备案条件的合同未予审批,原告为此承受了经

[21] See J. Burrell, How the machine “thinks”: Understanding opacity in machine learning algorithms, *Big Data & Society*, 2016, p. 2.

[22] See Monika Zalnieriute, Lyria Bennett Moses & George Williams, The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making, *Modern Law Review*, Vol. 82: 3, 2019, p. 442.

[23] See Charlotte A. Tschider, Beyond the “Black Box”, *Denver Law Review*, Vol. 98: 3, 2021, p. 690.

[24] See Cary Coglianese & David Lehr, Transparency and Algorithmic Governance, *Administrative Law Review*, Vol. 71:1, 2019, p. 20-22.

[25] [德]哈贝马斯:《在事实与规范之间》,童世骏译,生活·读书·新知三联书店 2003 年版,第 373 页。

济损失。在不予审批决定作出的过程中,原告始终未获得协商和申辩的机会,甚至向被告萧山区住建局提出也无济于事(被告辩称其并不具有网上备案系统的管理权限)。^[26](2)技术治理的“自我指涉”效应在一定程度上排除了协商程序的效用与意义。技术治理依赖的是一种“自给自足”式的运转逻辑,其在开始运行后便逐渐形成一个封闭系统,且很难从系统外部对其施加有效影响。也因此,当输出决策与现实存在偏差,而偏差又无法从外部化约为可以被系统所理解的语言时,偏差便无法纠正。这一问题在协商行政的语境下转化成两重交叠的困境:其一,当算法决策与社会现实产生偏差时,外部主体因缺乏对系统逻辑代码的实时认知,无法将外部判断转化为机器可识别的内部修正指令。其二,即便行政相对人通过协商程序与治理主体达成共识,此共识也因难以突破封闭的技术系统而失去意义,即协商行政无法发挥其决策理性失衡时的纠正功能。这两重困境使协商行政下的沟通程序适用意义面临质疑和挑战。

2. 技治逻辑与常规商谈逻辑存在明确差异,可能导致协商行政的空心化。具体而言:(1)技治的“非因果”逻辑使协商方之间难以达成实质认同。协商行政强调借助以因果关系为逻辑内核的说明理由环节,强化负担性结果的可接受性。然而,以大数据、算法为支撑的数字化治理通常是以相关关系逻辑作为分析、决策基础的,这种由“因果关系”向“相关关系”的逻辑转换,使相对人面对基于先验预测而非确凿事实作出的负担性决定时难以实质认同。(2)技治的“反常识性”阻碍了协商共识形成。技术治理的高度复杂性和技术性,使其决策所依据的事实、理由、结果在相对人看来可能是反常识的。例如,在2018年“何凯诉上海市公安局黄浦分局交通警察支队交通行政处罚案”中,原告何先生因涉嫌驾车在禁鸣路段违法鸣笛被处以100元罚款,但何先生对作为证据的照片(由内置声呐定位系统的电子监控拍摄)可靠性表示质疑,提出要求交警部门撤销处罚决定的诉请。^[27]该案中,以声呐定位系统抓拍的照片而非视频录像等常规电子证据作为处罚依据,一定程度上超出了原告的常识范畴。(3)技治的“非人格化”不利于协商方之间形成信任关系。在当下的数字化治理中,无论是决策内容还是相对人与治理部门的对话界面,都存在浓郁的“非人格化”特征。仍以“行人闯红灯抓拍系统”为例,假设行人闯红灯是为了庇护闯入熙攘车流中步履蹒跚的孙子女,则在交警现场执法的场景中行人基本不会受到处罚,因为作为执法者的交警本身具备并会自动在决策内容贯彻“人性”。而在以技治为驱动的决策过程中,“个案的特殊情形被强制服从于统计规律的普遍情形”,^[28]“有温度的执法”这一良性传统被破坏。相对人面对此类“冰冷”的惩戒处罚时,很难在协商中与治理部门形成友好互信的交流氛围。

(三)数字化治理推进引发责任行政“混沌”

相对人参与权实现需要对治理部门课以一种确保履行义务的义务,即责任行政的义务;当治理部门未能履行该义务时,就要承担相应的法律责任。总的来看,在数字化治理的推进过程中,责任行政面临着基本责任认定不明确、责任配置不清晰、监管机制缺位等现实挑战。

1. 数字化治理下基础责任认定不清可能导致责任行政的实效梗阻。公开行政与责任行政紧密相关——数字化治理的问责的标准流程往往要经历从“技术问责”到“法律问责”的过程,前者要求通过解码算法明确违法事实是否发生、如何发生、在何种程度上发生以及应当归责于谁的问题,后者则

[26] 参见浙江省杭州市萧山区人民法院(2018)浙0109行初228号行政判决书。

[27] 参见上海市第一中级人民法院(2018)沪01行初216号行政判决书。

[28] 雷刚、喻少如:《算法正当程序:算法决策程序对正当程序的冲击与回应》,载《电子政务》2021年第12期,第21页。

需将解码所得到技术结论转化为法律评价。^{〔29〕}在这一过程中,确定技术责任的重要前提便是驱动治理的算法具有充分的透明度,保障上述技术问责的目标可以达成;如果无法对算法充分解析,那么责任认定就可能与现实状况存在出入。这种由算法不可知引发的基本责任认定偏差,在公开行政异化的背景下,正在逐步演变成为一种稳固存在的问责块垒。

2. 数字化治理下责任配置不清可能导致责任行政的实效梗阻。较多学者指出,数字化治理中的责任配置难题体现在,算法的开发者、运营者或称外部技术主体是否应当承担责任,以及承担怎样责任。但如果将目光限定在参与权保障的语境中时,责任配置上的难题更多表现为,数字化治理经常执行的是多主体、多职权共同开展的综合性业务;而当前的问责机制仅以单一部门为问责对象,缺乏协同性问责机制,因此当协同性治理任务中相对人的参与权受遮蔽时,共同参与的各部门间应当如何合理承担相应的治理责任。

此外,数字化治理中还普遍存在着监管机制缺位的问题,可能造成责任行政的制度虚置。与“有权利必有救济”相对应,监管是义务、责任的核心实现机制,有责任就必须有配套的监管措施,否则责任便可能无法落地。

四、数字化治理下行政参与权遮蔽的生成逻辑之二:程序介质变化

程序作为权利实现的关键介质,其形态始终与所处时代的治理逻辑和物质技术条件深度关联。前数字时代的治理程序多呈现出单线程、单向度的线性运作模式;而当前依托于算法决策、数据中台等数字化决策与数据共享技术,治理程序设计正逐步向多线程、立体型、可视化的界面模式迈进。这种转型在时空间维度引发了结构性变革:时间层面,原本需根据时序安排依次完成的多个业务流程,如今可以通过虚拟平台同步并联处理;空间层面,以往需要行政相对人跨部门、跨地域递交材料的业务,现已整合至“一窗通办”或集中办公区的协同窗口。基于上述时空间上的压缩简省效应,本文将将其界定为“程序折叠”。这种程序的再造不仅重塑了治理行为的时空间结构,更是对相对人参与权实现的程度产生了深刻影响,当前,在上海率先部署开展并逐渐推行于全国的“一业一证”改革便高度展现出程序折叠的特征,以下将结合相关改革实践进行分析。

(一) 程序折叠中的流程再造及其产生的参与权遮蔽效果

1. 数字化治理中的流程结构的重塑。在传统治理情境中,各项行政程序是“按照时间轴串联的,一个行政机关办完转交下一个行政机关”,^{〔30〕}并直至整个治理程序结束,这在时间上呈现的是一种展开的状态。而在数字化治理时代,借助于数字平台和数据共享模式,治理程序实现了流程结构的再造,治理程序启动后,与治理相关的数据流会同时流向相关的各部门,使多项程序得以同时启动,由此在时间维度上呈现出一种“折叠”效果。以“一业一证”改革实践为例,“一业一证”对审批流程和审批模式进行了深刻改革,其主要采取“合并审查、一同核查”的策略:一方面,“一业一证”将一个接一个许可的“串联”审批转化为可同时进行多项许可的“并联”审批,《上海市浦东新区深化“一业一证”改革规定》中即规定“申请人的申请由浦东新区政务服务部门统一收件后,各有关审批部门应当并联

〔29〕 See Deven R. Desai & Joshua A. Kroll, Trust but Verify: A Guide to Algorithms and the Law, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 31: 1, 2017, p. 11.

〔30〕 王晓杰:《数字政府时代行政程序的结构性变革与价值整合》,载《浙江学刊》2025年第1期,第153页。

审批、限时办结,并由政务服务部门统一制作、送达行业综合许可证等文书”。另一方面,对于需要进行现场核查的事项,则由行政审批服务局根据审批事项对所涉部门进行统筹组织,通过联合勘查实现多个事项一次核查。

2. 流程再造引发参与权实现的“时间危机”。权利实现需要以时间为基础的程序保障,并联式行政程序虽然降低了治理的时间成本,但也造成参与权行使时长的压缩:以“一业一证”改革前后开设便利店为例,改革前相对人需要办理包括食品经营、酒类零售、烟草零售等5项独立许可,每张单项许可证都需单独申报;^[31]改革后仅需申办一个行业综合许可证,且“审批时限依照全流程中最短审批事项用时,限时办结”。^[32]就相对人的视角而言,改革前行政审批中所包含的各项许可程序是彼此独立的,这种展开式的审批虽然效率受限,但每一段许可程序中都为相对人保留了介入窗口期,相对人可在材料补正、陈述申辩、听证等环节行使自己的参与权。改革后多个许可程序整合成一个相对宏观的审批流程,这种并联机制实质地压缩了参与权行使的总时长,并由此造成了相对人参与权遮蔽的问题——假设串联审批程序中相对人参与权行使的时间为 $T_1+T_2+T_3+\cdots+T_n$,则在并联审批程序中相对人仅有单份参与权行使时间 T_0 。即便 T_0 可能大于单项 T_1 或 T_2 ,但“审批时限依照全流程中最短审批事项用时”决定了 T_0 的长度不可能超过行政审批程序中参与权的常规行权期限。

(二) 程序折叠中的法律关系隐匿及其产生的参与权遮蔽效果

数字技术嵌入治理活动实现了对“治理部门—相对人”关系的深度重塑。在传统治理情境中,治理部门与相对人之间一一对应的法律关系高度凝练、易于辨识。而进入数字化治理阶段后,一方面,数据与信息在政府内部的传导路径发生更易,与治理任务相关的多个部门能够同时启动治理程序;另一方面,数字化治理强化了部门间的协同关系,各部门基于“事本主义”和“场景牵引”在治理中形成信息共享、资源互补的程序格局。这两方面变革带来了治理流程一体化与多元法律关系隐匿化趋势。此时,治理的法律关系中的治理方已经变成一个职能综合化乃至“去职能化”的通办主体——仍以“一业一证”改革为例,“一业一证”强调对各类政府服务的前置整合,实现了“一表申请、一窗受理、综合收件、统一出件”,^[33]就相对人朴素视角而言,与其说自己在与多个治理部门打交道,不如说自己在与一个更宽泛的“政府”本身打交道。

法律关系是相对人观察自身权利义务群状态并采取相关举措的核心分析工具。事实上,各类细分的行政法律关系在数字化治理中依然切实存在并发挥着规范现实的作用,正如《上海市浦东新区深化“一业一证”改革规定》第14条规定的,“纳入‘一业一证’改革的行业,不改变该行业行政许可实施的法律关系。”而相对人对数字化治理中真实法律关系认知模糊化的原因,可以归结为“外部法律关系内部化”过程中的法律关系隐匿,即统一的窗口、数字化平台遮盖了治理流程背后真实发生的多重法律关系。此时,缺乏专业素养的相对人很难透过表象向法律关系中的真正主体提出正确的参与权诉求,或至少面临着参与权实现成本的增加,由此产生了参与权遮蔽。例如,在“综合查一次”中,相对人可能同时面对多个部门调查人员的询问,但“相对人并不知道其询问笔录会被哪一个机关适用

[31] 参见《国常会:在上海浦东试点“一业一证”,涉便利店等31个行业》,载澎湃新闻, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683132800968133380&wfr=spider&for=pc>, 2025年12月3日访问。

[32] 战旭英:《“一业一证”行业综合许可制度的实践探索及深化思路》,载《理论探索》2024年第5期,第74页。

[33] 石晋昕、杨宏山:《优化营商环境背景下政务服务整合供给的路径研究——以上海市浦东新区“一业一证”改革为例》,载《上海行政学院学报》2024年第4期,第57页。

哪部法律最终作出处罚决定”,^[34]此时,相对人自然无法向正确的主体提出正确的参与权请求。

五、权利找回:行政参与权与保障性义务的共时发展

如要探讨权利实现,就不能只探讨权利本身。事实上,我们仍可以对数字化治理中参与权遮蔽的原因作进一步凝练,即数字化技术对于治理部门和相对人双方的不对等赋能,使治理中固有的“权利—权力”平衡被打破。要找回被遮蔽的参与权,不仅要推动权利的迭代更新,还要对数字技术强化后的权力加以规训。这种规训不能是对于原有权力内容的纯粹削减,因为如此既可能打破传统治理场景中“权利—权力”的固有平衡,同时也可能形成不利于将数字技术引入治理的风气,使治理者为避免自身权力的削减而回避引进新的治理技术。此时就需要引入权利与权力的中间结构,即权利的保障性义务,逐步调整被打破的平衡关系。基于上述认识,本部分“找回”受遮蔽参与权主要沿两个方向展开。

1. 以保障性义务的补位回应因技术环境变动导致的参与权遮蔽。可以发现,在多数技术环境变动造成的参与权遮蔽情况中,相对人要求知情、进行陈述申辩、组织听证等参与诉求(即参与权的权利内容)依然是合理、正当的,但与参与权对应的保障性义务却不足以支撑权利实现维持在既有水平。例如,当治理部门基于相对人申请向其公开了海量、不加筛选的具体行政行为信息,若仅依据现有义务性规定,政府已经履行了公开义务,^[35]不同的是,相对人在获得公开信息后仍要付出额外的筛选与辨识成本。上述过程中,亟待强化、升级的,正是政府的保障性义务。

2. 以参与权的迭代发展应对因程序介质变化引发的权利遮蔽。权利实现的程序介质发生变化,意味着程序权利的行使条件随着数字化的宏观进程发生不可逆改变——除非数字化治理全面退回传统模式,否则既有程序权利与客观行使条件之间的裂隙将日益加深。此时,更需要推动作为程序权利的参与权与时俱进,以权利更新主动回应治理现实。

(一) 技术环境变动下的参与权找回:保障性义务补位

如前所述,在技术环境引发参与权遮蔽的较多情形中,“权利找回”需要的往往是更为周全的保障性义务。在数字化治理的语境下,保障性义务的完善能有效避免将权利直接暴露技术应用与传统法治的撕裂与倾轧中。具体而言,保障性义务宜从以下方面进行补位发展。

1. 以确保相对人能够实质理解治理信息、治理逻辑为落脚点,完善数字化治理中的公开义务规定,回应公开行政异化问题。对于信息素养普遍有限的相对人而言,运行可解释的算法不等于公开义务的全面履行,公开专有算法、算法的源代码及运行数据亦不等于公开义务的全面履行。欲有效回应数字化治理中公开行政异化,则治理部门必须对数字化治理的运转逻辑进行可被理解的解释,就如欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)第12条所规定的,数据主体获得的信息应当是以“透明的、可理解的和容易获得的方式,以清晰和平实的语言作出”。在负担性行政行为中,治理部门需格外关注公开的可理解性,应以尽可能消除认知落差为目标,以直观、可理解的方式通知告知相对人:(1)所认定的具体事实及已取得的证据;(2)适用的法律法规,如果作出的是裁量行政行为,还需要向相对人说明裁

[34] 王晓杰:《数字政府时代行政程序的结构变革与价值整合》,载《浙江学刊》2025年第1期,第154页。

[35] 当前我国《政府信息公开条例》没有明确就公开信息的有效性和有价值性进行规定,而只提到了“准确”的要求,从严格语义解释的层面来看,“准确”更多是关于信息相关性的界定,不能涵盖“有价值”和“有效性”的意涵,即便公开的是技术文档、运行日志,也是与具体行政行为相关甚至高度相关的信息,但其未必失于“准确”。

量理由;(3)可能发生的不利益后果;(4)参与具体行政行为的时间、地点和方式。

当然亦存在这样的疑虑,即机器学习算法的非线性、非人类逻辑和结构隐匿性等特征制约了完全解码的可能性,上述公开义务的履行将受到极大阻碍乃至无从履行。事实上,在技术层面上追求高度透明化是既无必要也难实现,通过技术工具的运用,治理部门完全可能在不披露完整算法模型的前提下向相对人展示与其权益直接相关的决策逻辑片段,或者围绕被解释的算法建立一个相对简单的模型以专门解释决策的支撑算法,^[36]并最终将所得的片段或数据还原为上述四项信息。可以见得的是,围绕实质可理解构建的公开义务可以有效规避基于知识产权专有保护或商业秘密等手段对算法内容公开的豁免。

2. 以实现治理部门与相对人间有效沟通为内核,建立数字化治理中的协商义务规则,回应协商行政萎缩问题。技术治理逻辑引发协商行政萎缩的核心原因,是治理部门与相对人双方在论辩环节无法达成有效的沟通,治理部门的保障义务应围绕促成双方的有效交互为核心来构建。首先,治理部门应当积极吸纳相对人进入协商论辩,并根据相对人情况确定协商的形式与主题,确保参与权的有效实现。具体而言:(1)治理部门应当主动通知在具体行政行为中的适格相对人参与协商,不仅包括行政行为的当事人,还包括有利益关系的第三人。(2)治理部门应当积极创造协商空间或平台,并根据相对人的具体状况确定协商的时间、主题、线上或线下参与等内容,为协商达成有效的成果提供形式保障。(3)为避免数字化治理中治理部门越过或过度压缩协商论证环节,还可强制性规定数字化治理决策必须经过有效的协商流程。其次,治理部门应着力为协商营造友善理性的环境氛围,促进双方充分表达。理性交流建立在“主体之间进行没有任何强制性、诚实的交往与对话”之上,并在“相互承认基础上达到谅解与合作”。^[37]数字化治理中,数字技术的不对称赋能使治理主体与相对人之间的地位差异越发显著,需要治理部门在协商过程中释放善意、真诚,从同情心和同理心出发对相对人的处境进行充分解读,尊重和承认相对人的正当利益诉求;治理部门还宜构建、引入算法决策的人工复核机制,对于明显的算法错误应及时纠正并向相对人致歉。此外,治理部门可通过向相对人适度地分享治理的背景、宗旨、目标等信息,增强相对人对治理活动的整体认同,减轻其因负担性行为而产生的隔阂心理。最后,治理部门需要在明确技术治理逻辑的基础之上,与相对人展开有意义的论证。一方面,治理部门需明确算法或自动化系统作出某项决策建议的基础逻辑,并在协商中将这种逻辑转化为相对人能够理解的言谈逻辑。另一方面,治理部门应当完整、充分记录相对人的意见与诉求,在客观公正研判的基础上回应、采纳其中合理内容。

3. 以确保各项治理责任可切实地落实为方向,完善数字化治理中的责任监督规定,回应责任行政混沌问题。回应责任混沌化最直接的方式,就是推动数字化治理中产生的各项责任切实落地。如前所述,目前数字化治理中的归责难题主要有二:其一,“机器问责—法律问责”转化过程中对事实还原度不足导致归责失真。对此,当前的技术水平尚缺乏有效解决途径,只能要求在尽可能还原责任事实的基础上进行归责,并最大限度地确保责任分配的公平、公允。其二,数字化治理框架中主体结构的综合化导致的归责难题。事实上,在数字化治理的情境中相对人并不需要考虑有哪些主体(技术主体、市场主体或治理主体)参与到治理之中,数字化产生的“信息鸿沟”使相对人不必亦不应去主动了

[36] See Lilian Edwards & Michael Veale, *Slave to the Algorithm? Why a “Right to an Explanation” Is Probably Not the Remedy You Are Looking for*, *Duke Law & Technology Review*, Vol. 16, 2018, p. 48.

[37] 郑召利:《哈贝马斯的交往行为理论——兼论与马克思学说的相互关联》,复旦大学出版社2005年版,第7页。

解治理的主体架构,相对人只需清楚向谁提请救济即可。在参与权遮蔽研究语境下,相对人寻求救济的对象简单清楚地指向了治理部门,至于治理部门在承担责任后会否向相关市场主体或技术主体进一步追责,则不在参与权遮蔽的研究视野之内。回应第二个归责难题的关键,在于治理部门应当合理确立并适用数字化治理中的协同性责任:(1)治理部门应当向相对人明示参与权遮蔽时的救济路径,尤其是寻求救济的对象,需明确到确切的部门即责任主体。由于数字化治理往往整合了多个部门的职权,并由一个“表象主体”与相对人进行对接交流,可能导致相对人在参与权未能得到充分实现的情况下向“12345平台”、城市运行管理中心等非行政主体机构提出权利救济,从而产生权利实现的额外成本。(2)治理部门宜建立并适用“联动式责任规则”,以确保责任分配的客观性、公平性与准确性。具体而言,责任分配可以遵从“先整体再部门”的原则——先建立多元行政主体的共同责任框架,以衡量因相对人参与权遮蔽所产生的整体责任;再根据治理所涉部门的过错大小对整体责任进行分割,将共同责任转译为各部门责任之和。

(二)程序介质变化下的参与权找回:参与权的迭代发展

从立法技术视角而言,相对人在程序介质变化中受损的参与性利益是可以通过推动立法中权利迭代发展予以弥补的,此处重点围绕三类参与权展开探讨。

1. 借助数字化治理“行动留痕、过程可溯”的特性发展知情权。面对数字化治理给知情权实现带来的严峻挑战,最有效的应对是确保在涉及利益处置的各个时间节点上,相对人都能获得有意义的通知或告知。而要实现这一权利愿景,有必要借助于“审计追踪”(audit trails,亦称为“审计跟踪”)这一技术手段。审计追踪能够记录系统作出每一个决策的事实基础与适用规则,^[38]记录下关于决策形成的“全面历史”(包括记录事实的个体及该个体的评估情况);通过审计追踪,治理部门可以向相对人提供支持数字化治理系统对其权利裁决处置的理由。^[39]审计追踪的不可篡改、可追溯和痕迹化特征,使其成为确保相对人获得有意义通知告知的重要技术依托。新时期知情权的实现路径,是将审计追踪嵌入数字化治理的具体流程之中,当检测到涉及权利的处置性行为时,便即时向相对人通知告知。可以预见,以审计追踪为技术驱动的知情权将衍生出新的特质:第一,知情权客体的复合性拓展。审计追踪与知情权的融合,是在并联流程中的各个关键性节点嵌入审计和反馈机制;在这一进程中,知情权客体从传统治理中的单一主体或单一行为转变为多重主体或多重行为,由此产生复合化和综合化的特征。第二,知情权范围的全面性延伸。审计追踪记录的是行政行为形成或决策作出的“全面历史”,将审计追踪与知情权相结合,相对人有可能获得关于行政行为更加充分的信息对称,实现对行政行为从事实输入到规则适用的全景式认知。第三,知情权权能的进阶性发展。传统知情权权能通常仅支持相对人公开基本事实和适用规则基础,而审计追踪能够对事实基础到规范适用之间的逻辑推演过程进行详尽记录。如果将这种推演过程纳入相对人知情权的请求范畴中,行政行为或决策便能以更高的“理性透明度”在相对人眼中呈现,知情权权能亦由此获得进阶乃至跨时代式的发展。

2. 发展、完善数字化治理中陈述抗辩权的保障性“制度群”。陈述抗辩权是一种高度“承上启下”的权利——该权利的实现高度依赖于有意义的告知、有效的沟通以及充分的理由说明。因此,要解决数字化治理时代的陈述抗辩权遮蔽问题,不仅要着眼于权利内容的适应性发展,更要强调与权利适配

[38] See Danielle Keats Citron & Frank Pasquale, The Scored Society: Due Process for Automated Predictions, *Washington Law Review*, Vol. 89:1, 2014, p. 28.

[39] See Danielle Keats Citron, Technological Due Process, *Washington University Law Review*, Vol. 85:6, 2008, p. 1305.

的保障制度体系的更新。首先,在事前阶段,宜扩展行政告知制度中告知的事项范围。行政告知是相对人行使陈述申辩权的前提,但当前各行为法对告知事项的规定不尽相同(参考《行政处罚法》第44条、《行政许可法》第30条)。在数字化治理情境下,行政告知的事项范围应当有所扩展,即相对人应当有权获知与其利益相关的行为、决策是否是由系统自动作出的。其次,在事中阶段,宜确立沟通交互环节的合理人员结构。合理的人员结构是实现有效沟通的重要前提,在数字化治理的情境下,除适格行政人员参与沟通外,必要时还可邀请第三方技术主体辅助沟通,为相对人行使陈述抗辩权提供更充分的事实和认知基础。最后,在事后阶段,宜构建数字化场景中的说明理由制度。相对人陈述申辩权的充分实现,有赖于其合理意见在最终决策中得到应有尊重。说明理由作为行政机关作出不利决定时或之后向相对人附随提供的依据,是相对人判断其陈述申辩权实现程度的重要依据。对此,宜规定行政主体须以可理解的方式向相对人说明行政行为中自动化系统与算法的应用情况。同时,鉴于公众技术素养的普遍水平,还应设立咨询专线,以便于提供进一步解释说明。

3. 新设数字化治理常态下人工服务的获取请求权或“可及权”。目前,多有学者从欧盟的GDPR、《个人数据保护指令》及我国《个人信息保护法》第24条等既有规则出发,聚焦于“反自动化决策权”(亦有称“脱离自动化决策权”或“自动化决策拒绝权”)的证成,这些探讨为数字化治理时代的人权保障提供了有益思路。然而,以GDPR中相关权利条款的实施状况为观察,反自动化决策权因其只适用于纯粹自动化决策、适用中易被宽松的豁免条款架空,以及权利条款并非以“可执行的状态”存在(该条款被多数成员国视为“禁令条款”而非“权利条款”),使该权利在实践中逐渐式微。^[40]

本文认为,在数字化治理时代为相对人增设普遍适用(即有限豁免的、去场景化的)的反自动化决策权具备相当难度,不妨适当转化新设权利的重心,即将“反自动化决策权”转变为“人工服务可及权”:一方面,宜将新设权利的属性从禁止权、抵抗权或更正权转化为获取请求权或“可及权”。就法理层面而言,当某项权利被界定为禁止实施某种行为的权利时,必须同时言明该权利适用的条件和边界,否则该权利会被发展中出现的各种特殊事由逐步架空。当前,要准确界定相对人在何种程度、哪些领域、怎样的时空条件下可以行使反自动化决策权存在极大困难,相较之下,明确相对人在受到侵害后可获得的救济或舒压渠道无疑更具可行性。另一方面,宜将新设权利的关注点从“自动化决策禁止”转化为“人工服务可及”。脱离或禁止自动化决策,首先要解决的问题便是,在信息不充分的前提下,相对人要如何认定决定就是通过自动化决策的方式作出的?且随着数字化深度嵌入行政过程,完全拒绝自动化决策将变得愈发困难。更可行的方法是在数字化治理中嵌入人工服务的可及权,该权利的首要权能并非“一刀切”式地将行政决策推倒重作,而是借助“人”的深度理性能力与情境感知能力,先行通过补偿不合理损害实现与相对人的和解,并在无法实现和解目的的情况下再行回溯至决策过程本身。如此,既可以有效避免行为或决策的沉没成本、推动数字化治理向更人性化方向发展,还能提升治理过程中相对人的体验以及治理决策的可接受性,可谓一举多得。

六、结语

参与权是现代民主的核心要素,其实现水平是民主发展的试金石。在规范化的参与下,相对人得以通过程序性渠道理解治理运作的逻辑,治理机构亦得以准确地识别相对人的利益诉求,这种双向的

[40] 参见唐林焱:《“脱离算法自动化决策权”的虚幻承诺》,载《东方法学》2020年第6期,第21-22页。

理性互动有效消解了传统统治下官僚部门与社会个体间的严格对立。参与权构建的双向沟通受到阻碍,不仅会造成利益诉求的上传迟滞,也会影响治理机构对核心矛盾的精准感知。本文以法定参与权在数字化治理中的实现难题为研究焦点,在构建权利遮蔽的分析范式基础上,从技术环境变动和程序介质变化的视角出发探索当前时代参与权遮蔽生成的逻辑所在,并尝试通过推进保障义务补位以及权利迭代发展的方式还原乃至提升参与权的实现水平。然而,当前本文为探索权利遮蔽而构建的范式模型仍相对粗疏,有待在后续研究中进一步精细化。

(责任编辑:郭海清)

Abstract: Rights obscuration refers to the phenomenon where the content of statutory rights cannot be fully realized due to changes in objective circumstances, with environmental shifts and alterations in foundational mediums being its key causes. In digital governance, individuals subject to specific administrative acts face the challenge of obscured rights to administrative participation, necessitating a systematic exploration of its underlying logic. Regarding environmental changes driven by technology, digital governance has led to the alienation of open administration, the contraction of deliberative administration, and the ambiguity of accountable administration, resulting in the obscuration of the right to administrative participation. As for changes in procedural mediums induced by digital governance, both the restructuring of process flows under procedural folding and the concealment of legal relationships have contributed to the obscuration of this right. In response, it is advisable to seek solutions by reinforcing protective obligations and promoting the iterative development of rights. This includes improving the administrative participation rights protection obligations of governance bodies by focusing on substantive comprehensibility, centering on effective interaction, and orienting toward genuine accountability. Simultaneously, the iterative development of the right to administrative participation should be advanced through three approaches: integrating technology with the right to information, enhancing the supporting institutional framework for the right to statement and defense, and establishing accessible rights to human-based services.

Key Words: digital governance, obscuration of the right to administrative participation, changes in the technological environment, changes in procedural mediums, reinforcement of protective obligations, iterative development of rights
